

1503912-15.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503912-15.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503912-15.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218940/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 26704394 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2218940 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE MARTINS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

ANDRÉ MARTINS DA SILVA, qualificado fls. 13, foi denunciado pelo incurso no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de agosto de 2022, por volta de 15h25, na Rua Ângelo Sans, nº 527, no Jardim Parque Zabani, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo 14 (quatorze) porções de cocaína, bem como ocultava outras 26 (dezessete) porções da mesma substância entorpecente, totalizando cerca de 23,0 gramas (consoante auto de exibição a fls. 11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 12), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse

da droga descrita acima, para comercializá-la no endereço supramencionado, mantendo parte da droga consigo e outra parte ocultada debaixo de uma pedra próxima a uma árvore existente no local.

Ocorreu que, policiais militares estavam em patrulhamento, quando visualizaram o indiciado mexendo na referida pedra e, por esse motivo, resolveram realizar a abordagem.

Realizada a revista pessoal, em poder de ANDRÉ, mais precisamente no bolso da calça, os agentes localizaram duas porções de cocaína e a quantia de R\$10,00 e, no short que ele vestia por baixo da calça, mais doze porções de cocaína e a importância de R\$75,00 em dinheiro.

Em seguida, os agentes realizaram a busca no local onde o indiciado estava mexendo e localizaram outras vinte e seis porções da mesma substância entorpecente.

Interrogado perante a d. Autoridade Policial, ANDRÉ optou por permanecer em silêncio (fls. 08).

Portanto, as circunstâncias da apreensão da droga, a forma de acondicionamento, a quantidade, o encontro de dinheiro aliada ao relato dos agentes públicos, evidencia que a substância entorpecente pertencia ao denunciado e que se destinava a entrega a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls.76) e apresentou defesa preliminar (fls.77/79). A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls.85/86). O réu foi citado e designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o acusado.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência da ação, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, ou, em caso de condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a fixação da pena base no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de constatação de fls. 12, laudo de entorpecentes fls. 73/75 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Julio Cesar Alves Moscardo e Lucas Balizardo Salgueiro deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e avistaram o acusado vasculhando uma árvore. Diante desta atitude ele foi abordado, e em suas vestes foram localizados dois eppendorf de cocaína e R\$ 10,00. Em busca minuciosa, viu que ele estava com outra roupa embaixo, e encontraram mais 12 eppendorf e R\$ 75,00 em dinheiro. Na árvore foram localizadas mais 26 eppendorf de cocaína. Não se recorda da versão dada pelo acusado. Não havia mais ninguém no local, apenas ele.

O acusado, em seu interrogatório, disse que estava no local na posse das duas porções de cocaína e R\$ 10,00 em dinheiro, e mais as doze porções e R\$ 75,00 na bermuda de baixo, tudo para consumo próprio. Que tinha acabado de comprar a droga de uma menina, que ela foi abordada junto, mas os policiais a liberaram por ser menor de idade. Que não estava vendendo drogas, e não tem conhecimento das drogas

achadas na árvore. Que é usuário de cocaína desde os 14 anos de idade, e estava em situação de rua fazia uns três dias. Estava desempregado quando foi preso.

Em que pese a negativa do acusado, estou convencida de que estava na posse dos entorpecentes para fins de tráfico de drogas, pois os relatos dos policiais militares são uníssonos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que eles inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicá-lo.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escoreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Ademais, é notório que à configuração do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado com o acusado para se atingir tal escopo, daí porque o fato dele não ter sido visto fazendo a venda ou entregando para alguém em nada altera a adequação típica de sua conduta.

A alegação de ser mero usuário de todo o entorpecente localizado não se sustenta. Primeiro que a quantidade de porções de cocaína é elevada, estava escondida no corpo do acusado em várias peças de roupas, que não se coaduna com a conduta de quem é mero usuário.

E alegando a condição de usuário, tinha o réu o ônus de comprovar as alegações, nos exatos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, mas disso não se desincumbiu, pois nenhuma prova veio aos autos que atestasse a sua condição de um viciado desenfreado em entorpecente, não sendo suficiente o mero relato em seu interrogatório judicial.

Nesse sentido:

“TÓXICO - Tráfico - Porte de “tijolinho” de maconha - Quantidade suficiente à confecção de oitenta cigarros - Ônus da demonstração de uso próprio pertencente à defesa - Presunção de destinação comercial - Admissibilidade - Recurso parcialmente provido para outro fim. O agente que, na via pública, traz consigo “tijolinho” de maconha, do qual se pode confeccionar cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa”. (Relator: Luiz

Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93).

"TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - Credibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368/76 - Inadmissibilidade - Finalidade comercial evidenciada nos autos - Diversidade (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento que respaldam a tipificação - Crime de natureza permanente que caracteriza-se com o simples fato de trazer consigo a droga - Ausência, ademais, de prova da exclusividade de uso próprio - Ônus da defesa - Sentença confirmada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 290.772-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal "JANEIRO/2000" - Relator: Debatin Cardoso - 20.01.00 - V.U.).

No mais, o só fato de ser um usuário de drogas, eventual ou compulsivo, não o impede de ser ao mesmo traficante, aliás, tal tipo de comportamento é comum.

Tem-se, pois, que a quantidade e forma de acondicionamento dos tóxicos, da variedade, além das circunstâncias da abordagem, não permitem a desclossificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, restando o quadro probatório firme e robusto, de modo de não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico pelo acusado.

Assim, à vista dos elementos probatórios carreados aos autos confrontados com o interrogatório do réu, só resta reconhecer a responsabilidade deste pelo delito de tráfico, impondo-se sua condenação.

Passo, então, ao cálculo da pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ré é primário e não ostenta antecedentes criminais. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e neste caso em concreto, o réu estava comercializando porções de cocaína, o que vem em seu desfavor, diante da natureza nefasta do entorpecente, com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só, deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Por tais razões, aumento a pena base de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Ausentes agravantes e atenuantes. Terceira fase: Ausentes causas de aumento de pena. Contudo, por ser o réu primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, diminuo a pena de 2/3, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou

incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível fixar outro regime que não o mais rigoroso. E no presente caso, considerando que a primariedade do acusado, mas diante das circunstâncias judiciais não lhe serem totalmente favoráveis, em especial pela quantidade de droga apreendida, cuja conduta contribuiu fortemente com a disseminação de drogas nesta cidade, a exigir maior rigor do Estado, fixo o regime intermediário para início de cumprimento de pena, que é o mais eficiente para prevenir e reparar o crime.

Por outro lado, não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Frente a este panorama, não se pode concluir que regime mais benéfico, neste caso, o aberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sejam suficientes para o real alcance da pena, que deve servir de fator de retribuição ao agente, de readaptação social e prevenção de novas transgressões.

E para o caso do acusado, que estava desempregado e se sustentando através do comércio odioso, procurando obter renda de um jeito mais fácil, o que revela total ausência de responsabilidade e auto disciplina, a substituição por penas mais brandas não lhe é socialmente recomendável.

A respeito do incabimento de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

“ (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). Portanto, cometido o crime na sua vigência, indevida a conversão da pena ou a concessão de sursis. 2. Recente entendimento do colendo STF afirma ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, Rel. Min. AYRES DE BRITO); todavia, deve ser ressaltado que foi (a) adotada em sede difusa; (b) por maioria de votos (6x4) e (c) sem efeito vinculante. 3. Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (...). (STJ, HC nº 203.403/ SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, d.j. 21/06/2011).

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Preso em razão do flagrante delito, a Lei nº 11.343/06 veda expressamente a concessão de liberdade provisória para aquele que praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 44). E ainda que assim não fosse, no presente caso se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime de tráfico de drogas enseja habitualidade e solto, nada impede que volte a delinquir. E o acusado permaneceu preso durante toda a instrução

processual, não havendo fato novo apontando a conveniência da sua soltura. E a quantidade de pena aplicada e o regime prisional gravoso exigem a custódia cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar ANDRÉ MARTINS DA SILVA às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 194 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, em favor da FUNAD, pois não comprovada a origem lícita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; c) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA